

1500680-22.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado NÍCOLAS ANACLETO DOS SANTOS foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha JOSÉ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, ., Centro - CEP 12630-000, Fone: (12) 3101-1424, Cachoeira Paulista-SP - E-mail: cachpta@tjsp.jus.br

1500680-22.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.

1500680-22.2022.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NÍCOLAS ANACLETO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra NÍCOLAS ANACLETO DOS SANTOS pela suposta prática de crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na denúncia narra-se que:

[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela Promotora de Justiça infra-assinada, no uso e gozo de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no incluso auto de prisão em flagrante, oferecer DENÚNCIA em face de NICOLAS ANACLETO DOS SANTOS, qualificado às fls. 06, pelo fato punível que passa a relatar.

Consta do incluso auto de prisão em flagrante que, no dia 18 de Julho de 2022, por volta das 16h10, na Avenida dos Puris, em via pública, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, NICOLAS ANACLETO DOS SANTOS, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 112 (cento e doze) eppendorfs contendo cocaína pulverizada, com peso líquido de 55,77 gramas e 112 (cento e doze) invólucros plástico contendo cocaína petrificada), popularmente conhecida como crack, com peso líquido de 19,5 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 23/25. Apurou-se que na data sobredita, NICOLAS ANACLETO DOS SANTOS encontrava-se junto de um indivíduo não identificado em um conhecido ponto de comercialização de entorpecente quando foi surpreendido por viatura polícia em patrulhamento. O denunciado, então, empreendeu fuga, lançando ao chão uma sacola plástica.

NICOLAS ANACLETO foi rapidamente alcançado pelos agentes e junto dele foi encontrado um telefone celular. Na sacola dispensada pelo denunciado durante sua fuga foram encontrados 112 (cento e doze) pedras de crack e 112 (cento e doze) pinos de cocaína.

O denunciado levava no bolso de sua bermuda a quantia de R\$160,00 (cento e sessenta reais) em notas diversas, posteriormente encontrada pelos policiais durante revista pessoal.

A natureza, quantidade, circunstância da apreensão da droga e a forma de acondicionamento, evidenciam que as substâncias se destinavam a entrega a consumo de terceiro. [...]

Às fls. 74/75, houve o recebimento da denúncia.

Às fls. 131/137, o réu ofereceu resposta a acusação.

Às fls. 167/170, negou-se a absolvição sumária do Réu e foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em 21/10/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o MP defendeu que: a ação deve ser julgada procedente com a incidência do artigo 40, inciso III da lei nº 11.343/06.

Em alegações finais, a defesa afirmou que: o réu deve ser absolvido face a insuficiência de provas, e subsidiariamente, pela aplicação da a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da autoria e da materialidade

Cuidam os autos de ação penal pública que visa apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas na modalidade consumada.

Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material.

O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Na situação ora em apreço, consigne-se, desde já, que a despeito das alegações da defesa técnica, as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 demonstra que foram apreendidas na posse do Réu 114 gramas de cocaína, tipo acondicionamento supositório e 26 gramas de Crack, tipo acondicionamento pedra.

Anote-se que, conforme conclusões do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 27/29, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 113/115 constatou que são substâncias entorpecentes as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06).

Trata-se precisamente de cocaína em 55,77 g de massa líquida; 19,5 de massa líquida de crack (fls. 27/29). Posteriormente em laudo pericial às fls.113/115 foi detectada a presença da substância cocaína dentre os entorpecentes averiguados.

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos

autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado NÍCOLAS ANACLETO DOS SANTOS foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha JOSÉ PAULO DA SILVA afirmou que: estava de serviço com o policial André, em patrulhamento na Vila Carmem; na Avenida dos Puris, havia 2 indivíduos (um deles era o Réu); os 2 fugiriam assim que viram a polícia; um deles atravessou o córrego e fugiu; o Réu, antes de sair com a bicicleta, dispensou uma sacola e saiu com a bicicleta; conseguiram abordar o Réu; voltaram e encontraram uma sacola com drogas e cocaína; deram voz de prisão e levaram à delegacia; o Réu fugiu de bicicleta; o outro fugiu a pé, mas abandonou a bicicleta dele no local; a sacola foi encontrada no mesmo local; foi o próprio NICOLAS que dispensou a sacola.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha ANDRÉ CARLOS RIBEIRO afirmou que: estava em patrulhamento pela Vila Carmem; entraram na Avenida dos Puris e viram 2 indivíduos; o outro policial acelerou a viatura para tentar abordar os indivíduos; ao perceber a viatura, um deles atravessou o córrego e conseguiu fugir; o outro indivíduo soltou uma sacola plástica e fugiu de bicicleta; conseguiram abordar esse indivíduo (Réu); na busca pessoal, não foi encontrado nada, só um celular; voltaram no local e encontraram uma sacola plástica com cocaína e crack; deram voz de prisão; não conseguiram as características do indivíduo que fugiu; no local, também ficou uma outra bicicleta, que devia ser do outro que fugiu; o Réu é conhecido e já foi abordado em outras ocasiões, no local em que há tráfico de drogas; até então, não tinham conseguido prendê-lo com a droga; conseguiram identificar que a sacola era a mesma que o Réu dispensou.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA afirmou que: a PM fez a prisão; foi encarregado da escolta; na cadeia pública, foi fazer uma revista minuciosa e encontrou R\$160,00 com o Réu; acionou o pai do Réu, já que ele tinha falado que tinha recebido do pai; o pai falou que desconhecia os valores (só tinha dado R\$20,00 dois dias antes); o Réu já era conhecido do ramo de tráfico; o pai falou que desconhecia o valor; relatou os fatos à autoridade policial, que determinou a apreensão dos valores; o Réu é conhecido dos meios policiais.

Em sua oitiva em juízo, a informante ELAINE CRISTINA BUENO DOS SANTOS afirmou que: o Réu estava fazendo tratamento contra o uso de drogas; o Réu estava usando muita drogas; o Réu é um menino bom; o Réu estava fazendo bicos; ajudava com os irmãos em casa, que sentem falta dele; nunca soube de envolvimento do Réu em tráfico de drogas; o Réu frequentava as biqueiras para comprar drogas; mesmo o Réu usando drogas, ele não era agressivo; o Réu estava com muito consumo de drogas; o Réu chegou a ser internado para uso de drogas; o Réu fez tratamento no PRAD por muito tempo.

Em sua oitiva em juízo, o réu NICOLAS ANACLETO DOS SANTOS afirmou que: nega os fatos; os fatos se deram numa segunda-feira; tinha ido ao local comprar cocaína; não pegou a bicicleta em momento nenhum; não tentou fugir; foi abordado e jogaram a sacola nele; a Vila Carmem tem muitos pontos de tráfico; não estava traficando no local; não estava de bicicleta; os R\$160,00 eram dele mesmo, pois estava fazendo bicos na feira; no dia dos fatos, não foi agredido, mas os policiais estavam “falando coisas”; os policiais civis ameaçaram; os valores foram encontrados a caminho do IML; estava afastado do tratamento há 10 meses; estava usando drogas todos os dias nesse período; só o policial civil já tinha “enquadrado” ele antes; ficou horas no camburão nesse dia; não contou nada para ninguém; só foi abordado dessa vez; o policial civil ameaçou falar para todos que ele era “cagueta”. Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que, na ausência de dúvida razoável sobre a parcialidade dos policiais envolvidos na operação, o seu depoimento é um meio idôneo de prova:

Apelação – Furto qualificado tentado – Condenação – Recurso da defesa – Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral harmônica e coesa – Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais,

normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato. (TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de ausência do laudo de exame de corpo de delito. Crime que deixa vestígios. Nulidade não reconhecida. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Reincidência descaracterizada. Documento que não traz informação acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Pena reduzida ao mínimo legal. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Restituição de bens e valores apreendidos. Impossibilidade. Objetos que interessam à persecução penal. Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500083-83.2019.8.26.0548; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (grifos acrescidos)

Os depoimentos colhidos foram coerentes entre si, convergindo quanto aos seguintes fatos: o réu foi abordado pelos policiais após tentar empreender fuga em sua bicicleta e descartar uma sacola plástica, que continha os entorpecentes apreendidos (fls.14/15). Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal:

Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33,

da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante - Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack - Réu que negou a prática delitiva - negativa que não prospera - Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack - Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas - Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes - condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria - Pena-base fundamentadamente exasperada - Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos)

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu NICOLAS ANACLETO DOS SANTOS, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto a culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o Réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu NICOLAS ANACLETO DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de

reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais na forma da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderá ser considerada negativa; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida dos acusados em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade dos réus, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: tendo em vista que a natureza e a quantidade da droga serão utilizadas para afastar a incidência do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, deixo de considerar tais circunstâncias nessa etapa da dosimetria penal, conforme entendimento do STF (tema 712).

Assim, a pena-base é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase não há atenuantes e agravantes a reconhecer.

Por isso, a pena intermediária é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Com relação à causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, é preciso destacar inicialmente o seu caráter objetivo, de sorte que ela incide se estiver caracterizada a proximidade, sendo irrelevante prova de que a conduta envolvia, de fato, o local que se pretende proteger:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AUMENTO JUSTIFICADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CONDIÇÃO OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

2. Não se mostra desproporcional o aumento da pena-base em 1/5 em razão dos maus antecedentes do réu (condenação pelo delito de tráfico de drogas prevista no art. 12 da antiga Lei de Drogas) e da quantidade de droga apreendida (21g de crack, acondicionados em 10 porções, e 56g de cocaína, divididos em 51 papérolas).

3. O agravante não preenche os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para ser beneficiado com o tráfico privilegiado, uma vez que possui condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas.

4. "A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma"(AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) 5. Recurso não provido.

(AgRg no HC n. 754.627/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.) (grifos acrescidos)

Sobre a causa de aumento, entendo que distâncias significativamente superiores a 200m dos estabelecimentos mencionados no dispositivo não permitem a aplicação da causa de aumento:

1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito. Provimento parcial do recurso defensivo.

2-) Materialidade delitiva e autoria não foram impugnadas e estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se imputar tráfico de drogas aos apelantes. 3-) Mudança na fixação da pena. Com relação a Leonardo, na primeira

fase, presentes três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, maus antecedentes conforme fls. 162/164 e 246, quantidade e diversidade (100 porções de cocaína e 37 de maconha) e o modo como agiram os apelantes, em concurso, visando dificultar a abordagem policial, justifica-se o acréscimo de 1/4, tendo-se seis (6) anos e três (3) meses de reclusão, além de seiscentos e vinte cinco (625) dias-multa. Relativamente a Gabriel, na primeira fase, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, quantidade e diversidade (100 porções de cocaína e 37 de maconha) e o modo como agiram os apelantes, em concurso, visando dificultar a abordagem policial, justificando-se o acréscimo de 1/5, tendo-se seis (6) anos de reclusão, além de seiscentos (600) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes para Leonardo, as penas permanecem a mesma da primeira etapa. Para Gabriel, vislumbra-se a agravante da reincidência específica (fls. 159/161 e 259). Com acerto agiu o d. Magistrado sentenciante, pois a fração de 1/5 mostra ser adequada para a correta retribuição e ressocialização. Cumpre consignar, porém, que o apelante agregou defensiva exculpante com evidente intuito de minimizar a responsabilidade criminal (confissão qualificada), não com a pretensão de auxiliar com o deslinde da ação penal e esclarecimento da verdade, tanto que admitiu a participação no delito, mas negou estar no local para perpetrar a traficância. Isso não é confissão. Logo, as penas perfazem sete (7) anos, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão, além de setecentos e vinte (720) dias-multa. Na terceira fase, não se aplica a diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Ela pode ser utilizada se, concomitantemente, o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, a quantidade de droga não é irrisória e há variedade. Ademais, Leonardo tem maus antecedentes, reitera na prática delitiva e Gabriel é reincidente. Por fim, não se provou a proximidade do estabelecimento de ensino, pois ele dista, a pé, 300 metros, para chegar-se a ele leva-se 4 minutos, conforme croquis de fls. 41, logo, pelo critério objetivo, não se percebe a maior facilidade para disseminar a droga entre estudante, professores e terceiros, afasta-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. As penas totalizaram seis (6) anos e três (3) meses de reclusão, além de seiscentos e vinte cinco (625) dias-multa para Leonardo e sete (7) anos, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão, além de setecentos e vinte (720) dias-multa para Gabriel. 4-) Regime inicial permanece o fechado, pela gravidade concreta dos crimes e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal). 6-) Os apelantes estão presos.

(TJSP; Apelação Criminal 0001894-31.2018.8.26.0535; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020) (grifos acrescidos)

MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - depoimento de policiais que indica que os réus atuavam juntos na venda de entorpecentes, um recebendo o dinheiro do usuário e o outro buscando a droga na pochete escondida na moita - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela - depoimentos que estão em sintonia com a confissão extrajudicial do acusado Moisés. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade, incomum com a figura de usuário; a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo; apreensão de quantia em dinheiro - visualização dos réus em local conhecido como ponto de tráfico e em atividade de mercancia - de rigor a condenação dos réus. CAUSA DE AUMENTO - prática do delito em proximidades de escola de ensino - inocorrência - a prova revelou que o local da traficância era exercida à distância de 400 ou 500 metros da escola - passagem obrigatória para a entrada na comunidade e não para o ingresso no estabelecimento de ensino - traficância que visava os frequentadores da comunidade - causa de aumento do artigo

40, III, da Lei de Drogas não configurada - provimento ao apelo dos réus. ASSOCIAÇÃO - ausência de provas de estabilidade e permanência - de rigor a absolvição - provimento ao apelo dos réus PENA - RÉU WILLIAM - base fixada no mínimo legal - ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes - causa de aumento afastada - redutor não reconhecido - manutenção - grande quantidade de droga apreendida - réu que alegou estar desempregado - indicação de profissionalização - demonstração de dedicação a atividades criminosas - improvimento ao apelo - RÉU MOISÉS - base fixada no mínimo legal - presente a agravante da reincidência - reincidência específica - aumento em 1/5 - confissão extrajudicial que foi utilizada como elemento de convicção - de rigor é o reconhecimento da atenuante - Súmula 545 do STJ - provimento para este fim - reincidência específica que autoriza aumento maior - compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão - manutenção do aumento em 1/5 - redutor não reconhecido em face da reincidência - causa de aumento afastada. REGIME - réus que se encontravam em poder de elevada quantidade de droga - natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - alta reprovabilidade e periculosidade - reincidência do acusado Moisés - o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) - regime fechado - necessidade - improvimento ao apelo - em face da alta reprovabilidade e do quantum de pena - inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito - improvimento ao apelo dos réus. DETRAÇÃO - não cabimento no presente caso - regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis - improvimento ao apelo. CONDENAÇÃO A CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - afastamento - inviável - de rigor a condenação - previsão legal - pagamento suspenso até que tenha o condenado condições de realizá-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - negado provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1501043-78.2019.8.26.0535; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020) (grifos acrescidos)

Por outro lado, o parâmetro de 200m é aceito pelo TJSP:

Revisão Criminal - Tráfico de entorpecentes - Pretensão à desconstituição do julgado com fundamento no art. 621, inciso I do CPP - Ausência de contrariedade à evidência dos autos - Condenação por tráfico ilícito de drogas amparada nas provas produzidas durante a persecução penal - Inexistência de ofensa ao texto expresso na lei penal - Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 - Impossibilidade - Conjunto probatório que confirma o intuito mercantil - Afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 - Descabimento - Proximidade do local de tráfico a duas escolas e uma praça - Distância de duzentos metros que se enquadra no conceito de "proximidade" - Ação revisional improcedente.. (TJSP; Revisão Criminal 0047174-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro de Poá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021) (grifos acrescidos)

Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e parágrafo 4º, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 - Conjunto probatório robusto, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime, as quais não foram contestadas pela Defesa - Afastamento da causa de aumento da pena relativa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 - Inadmissível - A circunstância em questão tem natureza objetiva, ou seja, para que seja aplicada, basta que seja comprovada a proximidade física entre o ponto de narcotraficância e o local previsto no referido artigo - No caso em tela, o crime foi cometido na mesma rua do estabelecimento de ensino "EMEB Profª Maria Benedicta Guimarães", no quarteirão ao lado, cerca de apenas 140 metros de distância, ou seja, dois minutos a pé - Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Criminal 0003579-95.2017.8.26.0248; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (grifos

acrescidos)

Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 - Recurso da acusação buscando o aumento da pena em face do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 - Acolhimento - A circunstância em questão tem natureza objetiva, ou seja, para que seja aplicada, basta que seja comprovada a proximidade física entre o ponto de narcotraficância e a escola mencionada no laudo de fls. 72/74, o que restou devidamente demonstrada, atestando-se que a escola fica apenas acerca de 180 metros do local onde o acusado praticava o tráfico - Recurso da defesa - Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena - Incabível - Réu ostenta reincidência específica - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Pena majorada e regime mantido - Recurso ministerial provido e recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500050-05.2019.8.26.0545; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/07/2020; Data de Registro: 18/07/2020) (grifos acrescidos)

No caso concreto, nota-se que a distância era de 130 metros (laudo de fls. 215/216), razão pela qual aplico o aumento de 1/6.

Diante disso, elevo a pena em 1/6 e fixo em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Além disso, é preciso enfrentar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, que exige a presença de quatro requisitos para a diminuição da pena: a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) ausência de dedicação a atividades criminosas; d) não integração de organização criminosa.

Em sede de julgamentos de recursos especiais repetitivos (Tema 1139), o STJ fixou tese no sentido de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

Desta forma, só é possível afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas se: a) houver maus antecedentes, inclusive por fato anterior à presente imputação, mas com trânsito em julgado posterior ao presente processo; b) houver reincidência; ou c) as circunstâncias do caso concreto (não outros processos) indicarem que não se trata de uma conduta pontual ou iniciante e que há efetiva dedicação a atividades criminosas ou pertencimento a organização criminosa. No caso concreto, não há prova de nenhuma das hipóteses acima, de sorte que entendo que é possível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Com relação à fração de diminuição, já que o dispositivo prevê uma margem de 1/6 a 2/3, a doutrina sugere a utilização dos critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas:

"91-C. Critérios para a diminuição da pena: o legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei: 'o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente'"(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, vol. 1, p. 424) (grifos acrescidos)

Considerando a apreensão de droga da espécie cocaína e em quantidade expressiva, sobretudo se considerada a traficância ordinária da região, a pena intermediária deve ser diminuída na fração de 1/6., razão pela qual fixo a pena definitiva em 04 anos, 10 meses de reclusão e 10 dias e 485 dias-multa.

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime SEMI-ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do CP, entendo pela

aplicação de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pois não há dados sobre a situação econômica do réu.
A quantidade de pena inviabiliza a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I) e a suspensão condicional da pena (art. 77).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o Réu NÍCOLAS ANACLETO DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 às penas de 04 anos, 10 dias e 10 meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial SEMI-ABERTO e ao pagamento de 485 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender condicionalmente a pena, nos termos da fundamentação acima.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).
Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus commissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes atribuídos ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. EXPEÇAM-SE guias de execução provisória e ofício de requisição. Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/2020.
DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.
Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais.
COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ).
Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena.
DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006), caso a providência já não tenha sido adotada.
Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cachoeira Paulista, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA